

1500828-49.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/03/2022

... é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500828-49.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500828-49.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2086933/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 17057752 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 830/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2086933 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 830/21/907 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTORIA APARECIDA MONTALVÃO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

RODRIGO BATISTA DE ARAÚJO, vulgo "Capital", e VICTÓRIA APARECIDA MONTALVÃO, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 29 de março de 2021, por volta das 15h40min, na Avenida José Detussi nº 100, Centro, no município e comarca de Sertãozinho, guardavam e tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 1.077 (um mil e setenta e sete) cápsulas de Cocaína pesando 890,67g (oitocentos e noventa gramas e sessenta e sete decigramas) e 203 (duzentas e três) porções de Maconha pesando 278,88g

(duzentos e setenta e oito gramas e oitenta e oito decigramas), substâncias entorpecentes e capazes de determinar a dependência física e psíquica. Consta ainda que, no dia 29 de março de 2021, pouco tempo depois das 15h40min, na Rua Jovita Maria de Jesus Souza nº 355, Conjunto Habitacional Vila Áurea Mendez Gimenez, no município e comarca de Sertãozinho, VICTÓRIA APARECIDA MONTALVÃO, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 01 (uma) porção de Maconha pesando 07,18g (sete gramas e dezoito decigramas), substância capaz de determinar a dependência física e psíquica.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, guardas civis municipais receberam uma informação anônima segundo a qual, próximo a uma horta de verduras, um indivíduo alcunhado como "Capital" e uma mulher estariam armazenando entorpecentes para a promoção do tráfico. Ao chegarem ao local, adentraram um matagal, e, cerca de quinze metros adiante, avistaram o réu Rodrigo, vulgo "Capital", na companhia da ré Victoria, tendo cada um deles fugido em direções opostas. Os guardas, então, se dirigiram ao endereço residencial da acusada e a encontraram lavando suas pernas. No imóvel, localizaram uma porção de Maconha e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), além de um telefone celular. Após, os guardas civis municipais retornaram ao local anterior e apreenderam 1.077 (um mil e setenta e sete) cápsulas de Cocaína e 203 (duzentas e três) porções de Maconha, diante do que a acusada foi presa em flagrante. Rodrigo, por sua vez, acabou sendo posteriormente preso pela prática de outro delito.

A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2021 (fls. 122/123). Os réus foram citados (Victoria - fls. 144 e Rodrigo - fls. 146) e apresentaram defesa prévia (Victoria - fls. 161/163 e Rodrigo - fls. 159/160).

Durante a instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo os réus interrogados ao final.

O representante do Ministério Público requereu a condenação de ambos os réus, nos termos da denúncia.

A Defesa da ré Victoria requereu sua absolvição, nos termos do art. 397, inciso III, do CPP, sustentando fragilidade probatória e que os depoimentos dos guardas são contraditórios. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa do réu Rodrigo requereu a absolvição do réu, por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a aplicação de regime diferente do fechado e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 17/18), pelas imagens fotográficas (fls. 19, 20, 21 e 22), pelos laudos periciais (fls. 100/102 e 103/105), conclusivos por se tratar de Cocaína e Maconha, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também está comprovada.

Os Guardas Civis Municipais Alefer e Gabriel, na fase policial, disseram que estavam em patrulhamento de rotina, fazendo averiguação acerca de tráfico de entorpecentes, nas imediações de hortas de verduras, onde um indivíduo, extremamente conhecido nos meios policiais por tais práticas, de vulgo "Capital", estaria juntamente com uma mulher, armazenando entorpecentes pelo local. Pois bem, ao passarem pelo sítio da denúncia, adentraram a um matagal, e realizando incursão, em uma distância de aproximadamente 15 (quinze) metros, viram claramente um homem vestindo uma bermuda jeans, camiseta regata escura e boné preto, juntamente com uma mulher (acusada), onde, com nitidez, condutor e testemunha puderam identificar, "Capital", pois os GCMS já o teriam abordado vezes anteriores, sabendo que este

participa do gerenciamento de uma parte do comércio de entorpecentes aqui nesta cidade. Como somente estavam condutores e testemunha, o casal observado, empreendeu fuga, fugindo cada um para um lado diferente, mas como os GCMs, já tinham conhecimento de onde a mulher, também identificada de momento, residia, foram até o endereço dela, onde presenciaram a mulher lavando suas pernas, onde realizaram a abordagem, localizando com a acusada, o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), na residência, 01 trouxinha de Maconha e o aparelho celular, ora apreendido. Na continuidade, indagaram-na sobre qual o seu relacionamento com o homem que correu, mas esta disse que o desconhecia, afirmando que estaria no mato, dando uma volta. Retornando ao local, contabilizou-se os entorpecentes encontrados, quais sejam, 1.077 (mil e setenta e sete) pinos contendo Cocaína em pó, 203 (duzentas e três) trouxinhas de Maconha, tudo dividido em chamados "kits", 27 (vinte e sete) de Cocaína, 06 (seis) de Maconha (fls. 06/07 e 08/09).

Em Juízo, disseram que um Munícipe parou a viatura e informou que "Capital", acompanhado de uma mulher, estaria adentrando uma estrada de terra para possivelmente armazenar drogas na mata. Avistaram uma trilha, na qual Victória estava agachada mexendo em uma bolsa e Rodrigo ("Capital") ao seu lado. Quando viram as viaturas, empreenderam fuga, não sendo possível alcançá-los. Como a ré já era conhecida nos meios policiais, foram até sua residência, sendo recepcionados por seu irmão, Guilherme, o qual franqueou a entrada no imóvel. Quando indagada sobre o porquê de estar na mata, a ré disse que apenas estava de passagem. A ré também admitiu ter drogas em sua casa, as quais eram para consumo pessoal e foram encontradas em seu quarto, além de uma nota de 50 reais. Na bolsa localizada na mata, foram encontradas mais de 1000 porções de cocaína e mais de 200 porções de maconha. Tem conhecimento de que a residência da ré é local de tráfico de drogas (v. mídia).

A ré Victória, interrogada na fase policial, disse que por volta de duas horas da tarde, saiu de casa para ir comprar alface em uma horta perto de sua casa, porém não conseguiu comprar. Disse que na volta para sua casa, caminhava por um caminho de terra, quando percebeu um indivíduo desconhecido, pardo, estatura mediana vindo logo atrás. Narrou que ficou com medo desse indivíduo e acelerou o passo, mas quando chegou em casa, alguns minutos depois, os Guardas Municipais ali adentraram e mandaram todos saírem do local. Disse ainda que no imóvel estava seu irmão Guilherme e um amigo de prenome Isaac. Informou não sabe declinar o endereço e telefone de seu amigo, que estava ficando em sua casa pois havia brigado com os pais. A ré disse que foi encontrada em sua casa, apenas uma porção de Maconha, utilizada uso e que o dinheiro é fruto de seu trabalho como diarista. Alegou que o restante da droga encontrada não é sua e não foi localizada dentro de sua casa. Por fim, disse que quando foi presa pelos GCM's a droga já estava dentro da viatura (fls. 10).

Em Juízo, negou a prática delitiva, alegando que estava na sua casa quando a GCM foi até lá e lhe disseram que a droga que estava na viatura lhe pertencia, tendo lhe mostrado apenas depois de lhe colocarem na viatura. Alega que a droga não era de sua propriedade, bem como não estava na mata, conforme narrado pelos policiais. Disse apenas ter ido a uma horta que havia lá embaixo e ter voltado de lá, não tendo avistado os guardas no trajeto. Foi até a horta perto das 2h30min, e cerca de 1h depois os policiais foram até sua casa. Não conhece Rodrigo. Em sua casa, havia uma porção de maconha em sua sapateira para consumo pessoal e uma nota de 50 reais, a qual foi dada por sua mãe (v. mídia).

O réu Rodrigo, interrogado na fase policial, disse que desconhece os fatos referentes à ocorrência em apuração. Negou que estivesse no local indicado pelos guardas municipais. Afirmou que não conhece a ré Victória. Alegou que não tem apelido e que não é conhecido por "Capital". Informou que mora no condomínio Honório Garcia. Não usa drogas, mas já usou. Informou que está preso em flagrante por tráfico de drogas, mas que a droga não era sua. Informou que trabalhava com grafito de parede. Informou que já teve passagens criminais anteriores por roubo e que está com alvará de soltura há quase 10 anos (fls. 109).

Em Juízo, negou a acusação, alegando que os policiais nunca o abordaram, apenas conhecendo-o por sua alcunha de "Capital". Não conhecia a ré Victória até tomar

conhecimento do processo. Não passa pelo caminho da mata, sendo distante do seu trajeto de rotina e de sua residência. Já foi preso anteriormente em posse de drogas. (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que os acusados eram realmente os proprietários da droga apreendida, e que se destinaria a consumo de terceiros.

Os Guardas Municipais Cíveis narraram de forma uníssona que, ao averiguarem uma denúncia anônima recebida, adentraram a um matagal e viram claramente um homem vestindo uma bermuda jeans, camiseta regata escura e boné preto, juntamente com uma mulher, identificando o homem visto como sendo a pessoa de vulgo "Capital", ora acusado. Os guardas ainda esclareceram que o casal empreendeu fuga, fugindo cada um para um lado diferente, mas como já tinham conhecimento de onde a mulher residia, foram até o endereço dela, local em que presenciaram a mulher lavando suas pernas, onde realizaram a abordagem, localizando com a ré o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), e na residência, 01 (uma) trouxinha de Maconha e o aparelho celular.

Ao voltarem para o local onde inicialmente viram os acusados, os guardas encontraram ainda 1.077 (mil e setenta e sete) pinos contendo Cocaína em pó, 203 (duzentas e três) trouxinhas de Maconha, tudo dividido em chamados "kits", 27 (vinte e sete) de Cocaína, 06 (seis) de Maconha, explanados pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16.

A toxicidade das substâncias apreendidas ficou constatada nos laudos periciais de fls. 100/102 e 103/105, concluindo-se por se tratarem os materiais de Cocaína e Maconha, respectivamente.

O réu Rodrigo, porém, alegou que não conhece a ré Victória e que não estava no local indicado pelos policiais, negando que usa ou trafica drogas.

A ré Victória narrou igualmente que não conhece Rodrigo e que na verdade, ele estava caminhando atrás dela, quando ela retornava a casa, ficando com medo e acelerando o passo. Narrou ainda que após ter chegado em casa, alguns minutos depois, os Guardas Municipais ali adentraram e mandaram todos saírem do local. A ré alegou que foi encontrada em sua casa apenas uma porção de Maconha que é para seu uso e que o restante da droga encontrada não é sua e não foi localizada dentro de sua casa. Que quando foi presa pelos GCM's a droga já estava dentro da viatura. A negativa dos réus, entretanto, não se respalda em qualquer prova produzida nos autos.

Houve por parte dos guardas municipais a confirmação de terem avistado os acusados no local dos fatos, logo após recebimento de notícia de crime por parte de um popular. A descrição feita pelo munícipe deu conta de ser um deles a pessoa do acusado Rodrigo, conhecido pela alcunha de "Capital". Já quanto a acusada, esta foi avistada juntamente com o denunciado, vasculhando e revirando monte de terra da horta onde os entorpecentes foram encontrados. Os acusados partiram em fuga após abordagem dos guardas municipais, deixando as drogas para trás. Neste contexto, embora neguem as imputações, de forma genérica, é possível tê-los como proprietários e guardiões das drogas.

As versões dos acusados sucumbem diante de suas presenças no local dos fatos noticiadas pelos guardas municipais. Os condutores da diligência foram enfáticos, uníssonos, sobre a identidade dos réus e suas condutas no momento da abordagem, presenciando a acusada Victória, em posição de agachamento, vasculhando uma sacola plástica enterrada no matagal e o corréu de pé ao seu lado, denotando atividade de guarda vigiada dos entorpecentes.

Os responsáveis pela ocorrência basearam-se em informações anteriores, feitas por um popular, para realizar a diligência que culminou no boletim de ocorrência e deram azo à peça acusatória, dando conta da presença dos acusados no local dos fatos e sobre a existência da guarda de entorpecentes.

Importa salientar que o espaço físico onde os acusados foram vistos não é utilizado geralmente para movimentação de pessoas, tornando-o próprio para guarda de substâncias ilícitas.

Assim, considerando que a significativa quantidade de droga encontrada é superior ao que normalmente encontrada com meros usuários, bem como a forma em que estava acondicionada, em porções individuais próprias para comercialização (fls. 19, 20, 21 e 22), conclui-se que efetivamente praticavam o tráfico na ocasião.

Observe-se que a credibilidade dos depoimentos dos guardas ainda vem corroborada pela prova documental e pericial já citadas, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que tivessem a intenção de prejudicar os acusados.

Ademais, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Reputo que a acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação dos réus como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu Rodrigo em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, perfazendo de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerando seus maus antecedentes (certidão de fls. 194/195 – autos nº 0007890-46.2008.8.26.0604). Quanto à ré Victória, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu Rodrigo é reincidente (v. certidão fls. 193 – autos nº 1501805-68.2020.8.26.0597), motivo pelo qual majoro sua pena em 1/5, alcançando 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa. A ré Victória, por sua vez, era menor de 21 anos na época dos fatos, porém tal circunstância atenuante não tem o condão de fazer com que as penas sejam reduzidas aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Neste sentido:

“O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada.” (STJ – HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que a ré Victória é primária e não ostenta maus antecedentes, também não havendo provas de que integre organização criminoso, reduzo as penas acima indicadas em 1/2 (metade), totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Assim o faço em razão da significativa quantidade de droga apreendida. Levo

em conta também a natureza de alta potencialidade lesiva da droga encontradas com os réus (Cocaína). Também deixou a ré de comprovar, por prova idônea, o exercício de atividade remunerada lícita. Assim, por tais motivos, merece ser duramente apenada e não pode ser beneficiada com a diminuição máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Quanto ao réu Rodrigo, impossível a redução de pena supracitada porque reincidente. Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano

a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta à ré Victória, nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal e do regime inicial fechado ao réu Rodrigo, notadamente porque reincidente.

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A propósito, ressalto que os acusados foram flagrados pelos guardas civis na posse e mantendo guardada significativa quantidade da droga Cocaína, em local conhecido por haver intenso tráfico de drogas. Ademais, a Cocaína tem grande potencial de causar rápida dependência e os réus ainda não comprovaram, de forma idônea, o exercício de atividade remunerada lícita, a merecerem serem duramente apenados. E pelos mesmos motivos que justificaram a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, decreto a prisão preventiva em desfavor do réu Rodrigo, para garantia da ordem pública, considerando sua reincidência, além de sua fuga quando dos fatos,

havendo risco para futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e art. 387, § 1º, todos do Código de Processo Penal. Assente-se que para decretação da prisão preventiva, por ocasião da sentença condenatória, é prescindível requerimento do órgão ministerial. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PERICULOSIDADE. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA SENTENÇA. ART. 387, § 1º, DO CPP. REGULAR APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão está fundamentada em elementos idôneos, destacada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do paciente. Os crimes praticados pelo acusado são de extrema gravidade, tendo ceifado a vida de uma vítima e, seguidamente, realizado roubo majorado contra uma segunda vítima, desta vez com restrição de sua liberdade e mantendo-a em seu poder, além de ter realizado ameaças graves a outras pessoas, testemunhas dos dois crimes, e também ter despejado o corpo daquela primeira vítima em lugar ermo e ateado fogo em um dos veículos subtraídos. 2. A prisão foi determinada em regular observância ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, considerando o Tribunal de origem que, ao prolatar a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta, sucedendo que, em tal dispositivo, não há previsão de que haja prévia manifestação ministerial quanto à decretação ou manutenção do ergástulo cautelar. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 683.987/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022).

Faculto o recurso em liberdade para a ré Victória.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus RODRIGO BATISTA DE ARAÚJO, vulgo "Capital", qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, e VICTÓRIA APARECIDA MONTALVÃO, qualificada nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo, como incursos no art. 33, "caput", c.c. § 4º, da Lei 11.343/06. Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Em face da condenação, os réus arcarão com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado Rodrigo, bem como guia de execução provisória.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 13 de março de 2022.

Angel Tomas Castroviejo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA